

1502738-59.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Thais Cristina Monteiro Costa Namba

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... para configuração do delito de tráfico de drogas, até porque estamos diante de tipo misto alternativo, o qual prevê, dentre tantos núcleos do tipo, aqueles apontados na denúncia como trazer consigo e guardar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Pleito de absolvição ou desclassificação
Impossibilidade - Materialidade, autoria e destinação dos entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502738-59.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502738-59.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2213672/2022 -

DEL.POL.S.VICENTE, EP8377-1/2022 - DEL.POL.S.VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELONÁRIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thais Cristina Monteiro Costa Namba

Vistos.

ELONÁRIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 e no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03, ambos c.c artigo 61, inciso II, alínea 'j", do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, na data de 06 de agosto de 2022, por volta das 13h10, na Rua Caimaiore, defronte ao nº 1483, nesta comarca de São Vicente, o denunciado trazia consigo drogas, sem autorização e para fins de tráfico, tendo praticado tal conduta em ocasião de estado de calamidade pública. Consta, ainda, que na mesma data, hora e local dos fatos, o denunciado portou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (fls. 58/59).

O acusado foi citado (fls. 77) e ofereceu defesa prévia à fls. 84.

Laudo químico-toxicológico (fls. 87/89).

Durante a instrução, foram ouvida duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 112/113 - mídia armazenada no SAJ).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 112/113 mídia armazenada no SAJ).

A Defesa, por seu turno, em relação ao crime de tráfico de drogas pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a incidência da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria. Em relação à posse de munições, pugna pela absolvição do acusado, arguindo ausência de comprovação da materialidade e aplicação princípio da insignificância.

Subsidiariamente, em caso de condenação pede a aplicação da pena-base pelo mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão e afastamento da agravante de calamidade pública. Em arremate, requereu a fixação do regime diverso do fechado para cumprimento de pena, além da aplicação da detração do tempo de prisão provisória para definição do regime. (fls. 112/113 - mídia armazenada no SAJ).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), auto de exibição e apreensão (fl. 16/17), auto de constatação preliminar (fl. 18/19), boletim de ocorrência (fls. 11/14), laudo químico-toxicológico (fls. 87/89), bem como pela prova oral coligida nos autos.

Interrogado em juízo, o acusado Elonário José dos Santos Júnior disse que, na data dos fatos, estava com as drogas em casa e teve sua casa invadida pelos policiais. Disse que as "balas" de munição encontradas não eram suas, que havia encontrado no lixo e iria tentar vender para ganhar um dinheiro. Quanto às drogas, disse que não vendia, apenas guardava também para ganhar algum dinheiro. Esclareceu que os cadernos que estavam na mochila não eram seus. Confirmou estar com a porção de drogas. Disse que já traficou drogas e já foi condenado anteriormente. Disse que saiu da cadeia há aproximadamente 02 anos. Reiterou que guardava as drogas para ganhar dinheiro e tentaria vender as munições para ganhar dinheiro, porém não sabia se estavam funcionando (fls. 112/113 - armazenada em mídia no SAJ).

Ouvida em juízo, a testemunha Luiz Henrique da Silva Goes, policial militar, disse que, na data dos fatos, estava em diligência pelas proximidades do local onde o réu reside, pois, havia ocorrido um roubo de veículo naquela data. Afirma que se deparou com um dos veículos roubados, que estava abandonado após a fuga dos criminosos. Disse que prosseguiu em diligência, quando recebeu informações via rádio de que sobre um indivíduo que havia se assustado com a presença de viaturas e entrado correndo em um sobrado. Relata que seguiu com sua equipe para averiguar a informação recebida, porém não possuía informação sobre número do imóvel, apenas a Rua Camaioré com a Rua 08. Que adentrou em um corredor da rua e viu um vulto. Ao se aproximar, viu o acusado, que ao avistar a viatura retornou e subiu correndo umas escadas. Afirma que também subiu as escadas e conseguiu abordá-lo em um corredor próximo a entrada de uma residência. Esclarece que o acusado estava com uma mochila que continha drogas, munições, celular e uma caderneta com anotações referentes ao tráfico. Dentro da mochila, pelo que se recorda, havia aproximadamente uns 400 eppendorfs de cocaína, droga similar a skunk, diversas porções de maconha e diversas pedras de crack. Disse que não conhecia o acusado de outras ocorrências, uma vez que o local não faz parte da circunscrição em que trabalha, sendo que estava em diligência em razão dos veículos roubados. Disse que quando questionado a respeito do roubo de veículos, o acusado chorou e admitiu apenas o tráfico. A munição e as drogas estavam todas juntas na mochila (fls. 112/113 - mídia armazenada no SAJ).

Ouvida em juízo, a testemunha Bianca Bento Ferreira, policial militar, disse que, no dia dos fatos, estavam em diligência pelo bairro Vila Margarida, com vistas a indivíduos que haviam realizado um roubo de veículo. Que localizaram o veículo abandonado nas proximidades e estavam em busca dos indivíduos que o roubaram. Afirma que o COPOM irradiou informação sobre um indivíduo em atitude suspeita e que este indivíduo havia ingressado em um sobrado ao avistar as viaturas nas

proximidades, mas não possuíam a informação sobre o número da casa. Relata que o comandante da equipe avistou o réu com uma mochila nas costas e que, neste momento, o réu correu e subiu uma escada. Disse que o réu foi alcançado e abordado em um corredor. Dentro de sua mochila foram encontradas as drogas e munições. Em relação às drogas afirmou que não lembra a quantidade exata, mas que havia cocaína, maconha e pedras de crack. Tinha também uma quantidade em dinheiro dentro da mochila, em uma sacola enrolada no dinheiro. As munições estavam dentro da mochila e eram cinco, mas não se recorda o calibre. Esclareceu que, no momento da abordagem, desceu para guardar a segurança da equipe e da viatura e quem manteve contato com o acusado foram o Sargento e o motorista (fls. 112/113 armazenada em mídia no SAJ). Verifica-se, pois, do conjunto probatório formado, que a autoria é indubitável e aponta para o réu.

Durante seu interrogatório, o réu confessou parcialmente os fatos. Disse que aceitou guardar as drogas visando receber em troca algum dinheiro. Quanto as munições, alegou que foram encontradas no lixão, sendo que as guardou porque também pretendia obter dinheiro com a venda do material, apesar de não saber se estavam hábeis ao uso. Negou que o caderno com anotações para o tráfico fosse seu. No entanto, a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos, diante do conjunto probatório formado contra si, a partir do depoimento harmônico dos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

Os policiais militares que participaram da diligência apresentaram relato coeso e harmônico, narrando que realizavam diligência nas proximidades do local dos fatos, a fim de localizar o autor de um roubo a veículo, o qual estava abandonado na via, quando foram informados via COPOM que o acusado foi avistado esboçando atitude suspeita com a presença das viaturas, tendo adentrado em um sobrado. Disseram que realizaram buscas pelo local e, em um corredor que dava acesso a uma residência, após subir uma escada, lograram encontrar o réu, que tentou se evadir. Afirmam que conseguiram abordar o acusado, o qual portava uma mochila e dentro dela lograram encontrar variada quantidade de drogas e algumas munições, além de uma caderneta com anotações referentes ao tráfico.

Nesse ponto, ressalto que o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas.

Neste sentido:

Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ, HC n.º 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018).

É também a posição reiterada do E. TJ/SP, alinhando-se ao entendimento dos Tribunais Superiores:

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapa do absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE Rel. Min. Carlos Ayres Brito j. 05.09.06;

HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96; HC 70.237 Rel. Min. Carlos Velloso RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.13; HC 177.980/BA Rel. Min. Jorge Mussij. 28.06.11; HC 149.540/SP Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.11 e HC156.586/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 27.04.10). (TJ-SP -APL: 30018581220138260082 SP 3001858-12.2013.8.26.0082, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/09/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 19/09/2016).

Ademais, não há qualquer vínculo entre o réu e os policiais, que sequer o conheciam, inclusive porque não atuam na circunscrição, fazem parte de outra Companhia e estavam no local diligenciando em razão de um roubo de veículo, demonstrando, com isso, a ausência de intenção de incriminar falsamente um inocente.

Aliás, rememoro que não há necessidade do acusado ser flagrado efetivamente realizando atos de comércio para configuração do delito de tráfico de drogas, até porque estamos diante de tipo misto alternativo, o qual prevê, dentre tantos núcleos do tipo, aqueles apontados na denúncia como trazer consigo e guardar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Pleito de absolvição ou desclassificação Impossibilidade - Materialidade, autoria e destinação dos entorpecentes suficientemente comprovadas. Palavra dos policiais às quais se confere relevo probatório. Desnecessidade de comprovação de atos de comércio. Crime de conteúdo variado. Elevada quantidade de droga, incompatível com a mera condição de usuário. Condenação mantida. Pena bem dosada. Regime fechado único adequado. Recurso desprovido." (TJ-SP APL nº 00038960920148260407 SP - 0003896-09.2014.8.26.0407, Relator(a): Camilo Léllis, Julgamento: 29/09/2015, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Publicação: 06/10/2015).

Em arremate, o laudo pericial de fls. 87/89 atestou que as substâncias analisadas se tratavam de TETRAHIDROCANNABINOL - THC (4,5g e 146,6g - fl. 88/89 - itens 01 e 04) e COCAÍNA (47,4g e 103,1g - fls. 88/89 - itens 02 e 03).

Desta feita, diante de tal cenário, não resta dúvidas que o acusado guardava e mantinha em depósito as drogas apreendidas e que, pela quantidade, variedade a forma como estavam acondicionadas, destinavam-se ao comércio ilegal, daí porque não há de se falar na absolvição do acusado.

De outro lado, em relação ao porte de munição, entendo que o delito também restou bem configurado.

Cediço que para configuração do delito em comento é prescindível a produção de prova pericial que ateste a eficiência do artefato bélico ou mesmo apreensão de arma capaz de disparar a munição, até porque estamos diante de crime de perigo abstrato.

Nesse sentido, a posição adotada na Quinta e na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03). ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE DE ESTAREM AS MUNIÇÕES ACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFIGURAÇÃO. Na esteira do entendimento desta Corte Superior, os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 são de perigo abstrato, de modo que a potencialidade lesiva é presumida, não havendo necessidade, para a configuração do delito, de estarem as munições acompanhadas de arma de fogo. DOSIMETRIA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DA PENA RELATIVA AO CRIME MAIS GRAVE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Este Sodalício já se pronunciou no sentido de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único por atingir apenas um bem jurídico, devendo ser aplicada somente a pena do crime mais grave. 2. Mais recentemente, porém, esta Corte Superior de Justiça vem entendendo que os tipos penais dos arts.

12 e 16, da Lei n. 10.826/03, tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático. 3. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a tese aplicada pelo juízo primevo, no sentido de que estaria caracterizado o crime único, tendo em vista que o apelo foi exclusivo da defesa, porém não deixou de observar, de maneira acertada, que o acusado foi beneficiado quanto à questão e que não seria cabível o pedido de aplicação da pena mais branda. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1122758 MG 2017/0155637-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018).

POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e ou munição, ante a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade de munição ou armas apreendidas. 2. Também é da jurisprudência iterativa deste Tribunal não ser necessária perícia para atestar potencialidade lesiva do artefato, justamente em razão da natureza do delito. 3. Por via de consequência, fica evidente que não há falar em inconstitucionalidade do crime, até porque é tema inapropriado ao veio do habeas corpus. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 411835 MG 2017/0199512-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA PARA APURAR LESIVIDADE. DESNECESSIDADE. 1 - O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é de perigo abstrato, sendo, pois, irrelevante e despiciendo fazer perícia no artefato para saber da sua potencialidade lesiva. Entendimento assente nas duas Turmas de direito penal no Superior Tribunal de Justiça 2 - Ordem denegada. (STJ - HC: 401096 SC 2017/0121953-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2017).

Também o posicionamento da 1ª e 2ª Turmas do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - AgR RHC: 146081 MS - MATO GROSSO DO SUL 4000284-55.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 10/11/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-262 20-11-2017) - grifei e destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na presente hipótese. 2. O delito de posse de arma de fogo, de seus acessórios ou de munições "contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a

prática de crimes" (HC 127.652, DJe de 17/6/2015). 3. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF - HC: 201203 SP 0052814-65.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/06/2021).

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação.

Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes.

Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RHC 138.843-Agr/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe RHC 212945 / SE 19.5.2017) - grifei e destaquei.

Outrossim, não há o que se falar em atipicidade material da conduta, em razão da pequena quantidade de munições apreendidas, até porque "não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas" (HC 206.977 Agr/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 08.02.2022). Dessa forma, restou bem delineada a responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o acusado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei 10.826/03.

Nessas condições e partindo do mínimo legal, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância do sistema trifásico (art. 68 do CP).

1) TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (art. 33, caput da Lei 11.343/06)

Na primeira fase da dosimetria, atenta às circunstâncias do artigo 59 do CP e, notadamente, do art. 42 da Lei 11.343/06, tendo em conta a natureza variada e vulnerante do entorpecente apreendido, bem como a grande quantidade encontrada em poder do réu (14 porções de skunk, 155 porções de crack, 400 eppendorfs de cocaína e 125 porções de maconha), majoro a pena base em 1/4, fixando a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência específica, cf. autos nº 0001113-39.2019.8.26.0158, com data de trânsito em julgado para a defesa em 23/05/2022 (fls. 33).

Presente, ainda, a atenuante da confissão, uma vez que o réu admitiu exatamente a conduta que lhe foi imputada (trazer consigo) em relação ao delito de tráfico ilícito de drogas.

Anote-se que a suposta invasão ao domicílio pelos policiais miliateres declinada pelo réu em seu interrogatório sequer foi levada em consideração ou mesmo aventada pela defesa técnica, daí porque não há como macular a confissão do acusado e afastar a incidência da atenuante.

Considerando o quanto decidido no Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não", promovo a compensação integral das circunstâncias agravante e atenuante, mantendo-se o patamar anteriormente adotado.

Rechaço, ainda, o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, sob pretexto do crime ter sido praticado em ocasião de calamidade pública. Respeitado entendimento diverso, alinho-me à interpretação de que, para a configuração dessa agravante, exige-se a demonstração de que o infrator, de algum modo, prevaleceu-se dessa situação fática para a

prática do crime.

E o que se viu foi justamente o contrário. A pandemia da COVID-19 trouxe mais pobreza e desigualdade social, colocando a economia do País em colapso, retirando-se dezenas de milhares de empregos formais do mercado de trabalho em razão do isolamento social, fato esse público e notório, o que motivou as pessoas a se colocarem no mercado informal do labor, respeitando ou não o isolamento social, condição esta última que somente foi agraciada aos mais privilegiados.

Sendo assim, entendo que não há nenhum nexos causal entre o estado de calamidade que vivenciamos em razão da pandemia do COVID-19 e a prática do delito de tráfico de drogas, na perspectiva de facilitação ou preavalecimento da situação desastrosa que a sociedade atravessou, motivo pelo qual fica rechaçado, com a devida vênia, o reconhecimento dessa agravante.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem outras causas modificadoras da pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena supra.

Anoto-se que, diante da reincidência do acusado, está obstada pela lei aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

2) POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (art. 14, da Lei 10.826/2003):

Na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, cf. autos nº 0001113-39.2019.8.26.0158, com data de trânsito em julgado para a defesa em 23/05/2022 (fls. 33).

Presente, ainda, a atenuante da confissão, conforme delineado no item “1” da dosimetria da pena.

Considerando o quanto decidido no Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”, promovo a compensação integral das circunstâncias agravante e atenuante, mantendo-se o patamar anteriormente adotado.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas especiais ou obrigatórias de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena sobredita. Em razão da regra esculpida no art. 69 do Código Penal e do cúmulo material das condutas, somo as penas, resultando-as em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, notadamente, a quantidade da pena, a reincidência específica do réu, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/2006 e dos arts. 33, §3º e 59 do CP da Lei 11.343/2006, fixo o regime inicial de pena como o fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do sursis penal, nos termos do artigo 44, incisos I e II, e artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Diante da ausência de elementos para se aferir a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar ELONÁRIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, porque sua prisão cautelar para garantia da ordem pública foi corroborada pela condenação e regime prisional ora fixados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso

III, da Constituição Federal.

Por fim, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Como trânsito em julgado, oficie-se, com as cautelas de estilo e lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos e a destinação do numerário ao FUNAD, oficiando-se.

P.I.

São Vicente, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA